

1502108-19.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

"Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei 6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 1502108-19.2021.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502108-19.2021.8.26.0542

Controle: 2021/001507

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

JEFFERSON ARAÚJO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, em 15 de setembro de 2021, por volta da 1h30min, na Rua Vicente Rodrigues da Silva, 100, Piratininga, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar: 50 invólucros plásticos contendo 46,5g de maconha, 77 invólucros plásticos contendo 7,05g de crack, 172 invólucros plásticos contendo 208,34g de maconha, 200 eppendorfs contendo 41,75g de cocaína e 92 invólucros plásticos contendo 6,58g de crack, todas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica. Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pela comunidade, conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com Jefferson ali parado.

Dado o horário e o comportamento suspeito, os milicianos efetuaram a abordagem. Em revista pessoal, lograram encontrar sacos plásticos escondidos em sua cueca, dentro dos quais havia 50 porções de maconha e 77 porções de crack.

Questionado, Jefferson confirmou a prática delitativa, bem como levou os policiais militares até um barraco abandonado dentro do qual localizaram o restante da droga, uma balança de precisão, uma máquina contadora de cédulas, bem como três sacos plásticos contendo eppendorfs vazios.

A denúncia foi ofertada e notificado Jefferson (fls. 116). Sobreveio a defesa preliminar (fls. 119/123) e não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 8 de novembro de 2021 (fls. 125/127). Jefferson foi citado (fls. 160/161).

Durante a instrução processual criminal foram ouvidas testemunhas (fls. 182/183) e interrogado o acusado (fls. 184).

Encerrada a instrutória, nada foi requerido, sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 185/186).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Jefferson nos termos da denúncia (fls. 194/200).

A Defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06 ou, ainda, pela aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 212/222).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

A materialidade delitiva consubstancia-se em auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 6/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo pericial de constatação (fls. 21/24), laudo pericial químico-toxicológico (fls. 106/109), bem como pelos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 182/183).

Perante a D. Autoridade Policial, Jefferson afirmou ser usuário de maconha e que estava fumando um baseado na favela quando foi abordado por policiais militares. Foi revistado e nada de ilícito encontrado consigo. Em seguida, questionaram se possuía passagens policiais, tendo respondido que sim. Passaram-se alguns minutos e os policiais apareceram com diversas porções de droga dizendo que iria assumir o B.O. na Delegacia (fls. 5)

Em Juízo, negou a prática delitiva. Declarou que estava na rua e foi enquadrado. Os policiais queriam a chave do caminhão. Respondeu que não sabia de nada. Disse que tinha passagem e os policiais disseram se preferia assumir um tráfico ou sequestro. Disse que preferia assumir o tráfico. Não indicou qualquer barraco para eles. Não estava com drogas. Cumpriu pena por roubo e terminou em 2019. Não estava trabalhando (fls. 184).

A negativa de Jefferson não encontra respaldo no conjunto probatório amealhado, desmerecendo, portanto, guarida. Veja-se que as narrativas de Jefferson, na fase policial e em Juízo, são contraditórias. Em Juízo afirmou que foi abordado pelos policiais que queriam chave de caminhão, respondendo que não sabia de nada. Os milicianos, então, indagaram se preferia responder por tráfico e sequestro, optando pelo primeiro. Na fase extrajudicial, entretanto, estaria fumando um baseado e foi levado pelos policiais militares, que lhe revistaram e nada encontraram. Passados alguns minutos os milicianos apareceram com diversas porções de droga, dizendo que iria assumir o B.O. na Delegacia.

A testemunha Policial Militar Marcos asseverou que em patrulhamento no local dos fatos avistaram o acusado com volume na cintura. Fizeram a abordagem e em revista pessoal foi encontrado nesse volume entorpecente. Conversaram com o acusado e indagaram onde guardava entorpecente. O acusado indicou um local na Comunidade Flamenguinho, tipo Q.G., onde foram apreendidas mais drogas armazenadas em grande quantidade, bem como balança e noteiro.

As drogas estavam nas partes íntimas do acusado. Ele não confirmou a participação no tráfico, mas indicou o local onde armazenava drogas. Afirma que chegaram no barraco por indicação do acusado. O barraco estava fechado, porém pela abertura das telhas conseguiram visualizar que se tratava de um local para armazenamento da droga. Não havia ninguém ali e não era um local de residência. Então adentraram no local. Apenas visualizaram o acusado na rua. Afirma que abordaram o acusado com as drogas e ele inicialmente desmentiu que estava no tráfico, porém a quantidade da droga já indicava o tráfico. Conversaram com ele a respeito disso e ele então indicou onde guardava o restante do entorpecente (fls. 182).

A testemunha Policial Militar Erick declinou que em patrulhamento no local, se depararam com o acusado e o abordaram. Em suas vestes houve apreensão de quantidade de drogas. Indagado onde havia mais drogas ele apontou o local. Pelas frestas do telhado viram que ali havia mais entorpecente e apreenderam mais drogas, eppendorffs vazios, apetrechos e noteiros.

O local onde fizeram apreensão de mais drogas fica a 500m do local da abordagem.

Pelo que viram, o local era um cômodo vazio onde só deixavam entorpecentes.

O acusado foi abordado sozinho e não havia pessoas próximas. Ele foi bem solícito e tudo o que perguntavam ele colaborou.

A porta do barraco estava encostada. O acusado informou que o barraco era utilizado somente para guarda da droga. Não conhecia o acusado e foi a primeira vez que o viu. Chegou a perguntar onde o acusado morava, mas não se recorda mais onde ele informou (fls. 183).

Os testemunhos policiais demonstram a veracidade dos fatos, até porque responderam às indagações formuladas, apresentando as mesmas circunstâncias, tanto no aspecto principal quanto no secundário, quer na fase extrajudicial como em Juízo.

É cediço que o testemunho policial não é afetado, positiva ou negativamente, pela função que exerce. A condição funcional não confere ao seu testemunho maior força persuasória e nem o inquina de suspeição. O valor probante de sua versão é aferido pelo mérito e de acordo com o grau de confiabilidade segundo a harmonia das provas coligidas aos autos. Neste sentido, vasta é a jurisprudência proclamada pela suficiência, se coesos os testemunhos policiais, para embasar o édito condenatório.

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial” (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).

“TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha afim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.).

As provas são uníssonas e coesas quanto à responsabilidade criminal de Jefferson. Ele foi abordado, com um volume na cintura. Revistado, nesse volume, foi encontrado entorpecente, 50 porções de maconha e 77 porções de crack. Jefferson indicou um barraco, o qual estava aberto e sem habitantes. Conforme relato dos milicianos, Jefferson informou que o barraco era utilizado somente para armazenamento de drogas. Os policiais militares ingressaram no casebre e apreenderam mais entorpecente.

Para caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes dever-se-á atender à natureza e a quantidade da substância entorpecente, ao local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Seguindo essas variantes houve plena demonstração do animus de traficar, sendo robusto o material cognitivo.

Ora, os elementos citados são suficientes e indicam que o material tóxico apreendido se destinava ao comércio ilícito.

Jefferson foi denunciado por trazer consigo, ter em depósito e armazenar substância entorpecente cuja finalidade é o comércio. O tráfico de entorpecentes, como é cediço, é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo.

“Tóxico. Tráfico. Caracterização. Para caracterização do delito do art. 12 da Lei

6.368/76, da modalidade de tráfico, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a confissão extrajudicial, a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes dos agentes, bem como as circunstâncias da prisão, evidenciem a atividade delituosa" (TJRJ - ApCrim 5.492 in Direito Concreto, v. 5, p. 191).

"Desimporta se o agente não chegou a vender o tóxico, pois trazer consigo, já é delito consumado, segundo uma das normas múltiplas que contém o art. 12 da lei respectiva" (TJRS - AC 68.305.178-3 - Rel. Milton dos Santos Martins - RJTJRS 107/59).

Com esta prova a respeito da finalidade de entrega do entorpecente a consumo de terceiros não há que se cogitar da desclassificação para o delito preconizado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Anote-se que a condição de usuário não exclui a traficância.

Conclui-se, pois, pela procedência da ação penal e consequente condenação de Jefferson Araújo da Silva por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Não agiu com intensidade dolosa incomum para os delitos da espécie a justificar a exacerbação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do autorizado pelo artigo 59, do Código Penal.

É reincidente, ex vi da informação trazida pela certidão criminal de fls. 46/47 (proc. 0015206-13.2017, da Quarta Vara Criminal Local), dando conta de anterior condenação, sem que tenha havido o transcurso do quinquênio depurador. Assim, observada a reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, a reprimenda será exasperada na proporção de 1/6. Vale anotar que a Lei 11.343/06 não define o que seja reincidência, aplicando-se, portanto, a previsão do Código Penal. Como é bem sabido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, o Código Penal não distingue entre reincidência genérica e específica, usando, tão-somente, o critério temporal.

"Como regra geral, o Código Penal afastou a chamada reincidência específica, sendo suficiente a prática de crime anterior - independentemente das suas características -, que pode ou não ser idêntico ou ter o mesmo bem juridicamente protegido pelo crime posterior, praticado após o trânsito em julgado da sentença condenatória" (GREGO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral, 14. ed., Ímpetus, 2012, p. 568).

"PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DEMULTA. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ALÉM DO FATOR DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 269 STJ. ORDEM EM PARTE CONCEDIDA. 1. O cometimento de novo delito acarreta o reconhecimento da agravante da reincidência em virtude do anteriormente praticado, inexistindo qualquer distinção acerca do tipo de crime perpetrado ou de pena aplicada, nos termos do artigo 63 do Código Penal. 2. A mens legis da norma consiste em apenar de uma forma mais gravosa aquele que apresenta uma tendência à prática delitiva, mesmo que de pequena expressão o crime ou a pena. 3. Imposta pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e favoráveis as circunstâncias judiciais, deve ser aplicado o regime semiaberto ao acusado reincidente. Súmula n.º 269 do STJ. 4. Ordem parcialmente concedida a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente" (HC 235481/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgamento: 17/05/2012, DJe 28/05/2012).

Ainda, o reconhecimento da reincidência, como agravante e causa obstativa de concessão de benefício não constitui bis in idem, conforme o assentado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 196197-RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, Julgamento: 16/8/2021. Publicação: 5/9/12), quanto pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 453.000-RS, Relator Ministro Marco Aurélio, Julgamento: 4/4/2013. Publicação: 3/10/2013).

Não é pertinente a redução prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reconhecida reincidência de Jefferson.

"Importante ressaltar que o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº11.343/06, não é direito subjetivo do acusado. O legislador, ao adotar a expressão "poderão", quis demonstrar, com todas as letras, que se trata de mera

faculdade do Juiz sentenciante que, na dosimetria da pena, tem, obrigatoriamente, de seguir a diretriz prevista no artigo 42 da referida lei, que demonstra como a pena deve ser aplicada. Em outras palavras, se o legislador entendesse que a benesse acima mencionada era direito do réu, teria usado a palavra "deverão", oriunda do verbo "dever", que significa obrigação, necessidade, etc. Assim, como o texto do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, está redigido que "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços", não há qualquer dúvida que a concessão do benefício depende do livre arbítrio do Juiz, que, como já dissemos acima, tem de levar em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, e também o artigo 42 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (HABEAS CORPUS Nº 293.891 - SP (2014/0104066-0) - RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ADVOGADO: OTONIEL KATUMI KIKUTI - DEFENSOR PÚBLICO - IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PACIENTE: WESLEI FRANCIMAR DE ABREU).

Cabe, ainda, ressaltar que, não sendo o acusado o produtor da droga, adquire ele o entorpecente de outrem, os quais estão vinculados a atividades criminosas antecedentes (Apelação 0049725-63.2007.8.26.0405 - Relator Amado Faria - 8ª Câmara de Direito Criminal - Tribunal de Justiça de São Paulo - 19/4/2012).

Considerando os parâmetros acima e os demais critérios preconizados pelo artigo 59, do Código Penal, fixo, a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na base. Pela incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, exaspero a reprimenda em 1/6, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados na base. Não há outras agravantes ou atenuantes. Não há causas de diminuição ou de aumento. À míngua de outras causas legais de alteração torno esta pena definitiva. Em face do disposto na Lei 11.464, de 28/3/2007, fixo o regime inicial fechado, com a progressão prevista na referida legislação para o apenado, notadamente reincidente.

Outro regime que não o inicial fechado não será o suficiente para a prevenção e repressão delitivas.

Trata-se de crime de natureza grave, equiparado a delito hediondo, que causa perturbação da ordem pública, atingindo o bem-estar (Saúde) - direito constitucionalmente assegurado e de primordial relevância, sendo o tráfico de drogas a mola propulsora que frontalmente contraria este princípio; além de fomentar outros crimes de elevada gravidade. Nos termos do artigo 33, § 3º, c.c. o artigo 59, caput, ambos do Código Penal, observando-se que Jefferson demonstra maior e mais intenso envolvimento com a prática delitiva, sendo que ele além de levar entorpecente consigo tinha, também, acesso ao local de armazenamento, entendendo necessária a fixação do regime mais gravoso, sendo que o regime prisional intermediário não bastará à repressão e prevenção delitivas, dado o desajuste à convivência social por ele demonstrada.

A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, trazida ao Código Penal pela Lei 9.714/98, é incompatível e inaplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista a vedação imposta pela Lei 8.072/90. Ora, admitir-se a substituição da pena privativa de liberdade em crime desse jaez é ignorar o dever assumido pelo Brasil no combate ao tráfico de entorpecentes.

Se a quantidade da pena imposta e que obsta a substituição, já que superior a quatro anos, esse beneplácito se restringe à pequena e à média criminalidade nos quais não se justifica a retirada do agente da Sociedade, de acordo com a Exposição de Motivos do então Projeto de Lei 689 de 18/12/1996. Não é, pois, passível de extensão a delito assemelhado a hediondo, pela sua reconhecida perniciosidade à Sociedade.

Apesar da grave ameaça ou violência à pessoa não integrar o tipo penal do tráfico de entorpecente, não se pode olvidar que se trata de elemento significativo que flagela a Sociedade.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO JEFFERSON ARAÚJO DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 11.464/07.

O apenado foi colocado em liberdade no encerramento da instrução processual e assim poderá recorrer.

Nos termos do artigo 60, c.c. o artigo 63, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 125, do Código Penal, atendido ao requisito do artigo 126, do Código Penal, e a teor do artigo 127, do Código Penal, decreto o perdimento do numerário apreendido, dada sua origem ilícita.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos termos regimentais. Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 14 de janeiro de 2022.